

1500171-05.2022.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... ser-lhe aplicados os benefícios do tráfico privilegiado, nos termos do § 4, art 33, da Lei de Drogas. Não havendo qualquer indicação de integrar organização criminosa, nem mesmo de "mula" do tráfico, ponderou que deve haver a redução máxima da pena, com a fixação da pena em regime aberto e substituída pela restritiva de direitos, em consonância com a jurisprudência dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

1500171-05.2022.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Aos 06/10/2022 10:14:24 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a) Juiz(a) de Direito desta Comarca, o(a) Exmo(a) Sr.(a) Dr.(a) Viviane Cristina Parizotto Ferreira, para deliberações. Eu, Wellington Rodrigo de Souza Bosso, Assistente Judiciário, subscrevi.

Processo nº:

1500171-05.2022.8.26.0585

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BEATRIZ DOS SANTOS GILES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de BEATRIZ DOS SANTOS GILES, qualificada a fls. 29, e em face de VINICIUS DE FREITAS, qualificado a fls. 17, dando-os como incursos nos artigos 33 e 35, com as circunstâncias delineadas no artigo 40, incisos III e V, todos da Lei 11.343/06, pois no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 2h30min, na Rodovia SP 270 Km 616+500m, neste município, os réus transportavam, para fins de tráfico, três pacotes plásticos transparentes, os quais envolviam em dois deles três invólucros plásticos e no outro pacote mais dois invólucros plásticos, todos contendo em seu interior substância conhecida como Haxixe (maconha), somando-se cinco invólucros em forma de tabletes (todos in natura), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme faz certo o laudo pericial de fls.

45/51.

Segundo consta na denúncia, durante procedimento de fiscalização na Rodovia Raposo Tavares, policiais militares pararam um ônibus coletivo itinerário Ponta Porã/MS a São Paulo/SP, e ao abordarem os indiciados que se encontravam nas poltronas 33 e 34, localizaram dentro da bagagem de mão da passageira Beatriz, uma bolsa de mão de cor rosa, a quantidade de droga acima mencionada. Na ocasião, durante o procedimento, ao serem indagados alegaram que haviam sido contratados por uma pessoa desconhecida na cidade de São Paulo, para buscarem a droga apreendida na cidade de Ponta Porã, também de pessoa desconhecida e levar para a cidade de São Paulo, visto que com isso ganhariam a quantia de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada um. Por fim, foram apreendidos ainda, dois aparelhos celulares, dois tickets de passagem e um ticket de bagageiro. São confitentes quanto à quantidade de drogas encontradas no interior da bolsa de mão da indiciada Beatriz, sendo seu amásio Vinicius conivente (fls. 11). Em razão da quantidade, espécie e forma de acondicionamento da droga apreendida, conclui-se que o entorpecente era destinado ao tráfico. Requereu seja reconhecida a perda em favor do Estado ou de entidade beneficente especializada no tratamento e recuperação de viciados, os objetos apreendidos, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06 (fls. 11).

A denúncia (fls. 142/143) veio acompanhada do incluso inquérito policial nº 76/2022, iniciado mediante flagrante (fls. 01/03).

Folhas de antecedentes e certidões criminais dos réus a fls. 60/65.

Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva dos réus. Outrossim, deferiu-se a quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho de telefone celular apreendido com o réu (69/75).

Mandado de prisão preventiva cumprido e encartado a fls. 97/98.

Após solicitação da Secretaria da Administração Penitenciária e manifestação do Ministério Público, sobreveio decisão a fls. 117/118 dispondo que, sem olvidar dos fundamentos bem lançados no "Habeas Corpus Coletivo", que, acertadamente, ratificam a excepcionalidade da prisão e a necessidade de zelar pela proteção de nascituros, crianças e adolescentes - dever do Estado, constitucionalmente previsto - a autuada deve ser mantida sob custódia cautelar pelas razões expostas, enquadrando-se, o caso aqui tratado, das hipóteses excepcionálíssimas lá previstas, indeferindo o pedido de prisão domiciliar da ré Beatriz.

Laudo de exame químico toxicológico a fls. 131/133.

Houve pedido de reconsideração da decisão de fls. 117, para substituir a cautelar em domiciliar ou aplicar as medidas alternativas do artigo 319, do CPP (fls. 146/147), o qual, após oitiva do Ministério Público (fls. 161/164), foi indeferido (fls. 166).

Sobreveio pedido de informações em Habeas Corpus impetrado em favor da ré Beatriz, cuja decisão indeferiu a liminar pleiteada (fls. 169/187), sendo certo que foram prestadas informações a fls. 190/192.

O réu Vinicius apresentou defesa prévia a fls. 188, por meio da qual a defesa alegou que provaria a inocência do acusado no transcorrer da instrução.

Por sua vez, a ré Beatriz apresentou defesa prévia a fls. 201/205, através da qual a defesa requereu a rejeição da denúncia, com fulcro nos art. 395, III, do CPP, considerando a ausência de justa causa para a ação penal; bem como a revogação da prisão cautelar, sem ou com a aplicação de medida substitutiva ao cárcere (CPP, arts. 319 e 320), preferencialmente o comparecimento periódico em Juízo.

Parecer do Ministério Público a fls. 209/210, opinando pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória formulado pela ré Beatriz.

A defesa do réu Vinicius requereu que seja relaxada a prisão preventiva, ante sua ilegalidade, e caso este não seja o entendimento do Juízo, que seja deferida liberdade provisória ao réu, que está sendo acusado de crime que não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça (fls. 212/224).

O Exmo. Promotor de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pelo réu Vinicius (fls. 240/241).

A defesa da ré Beatriz peticionou a fls. 243, aduzindo que impetrou Habeas Corpus em favor da constituinte, o qual foi julgado na data de 19/09/2022, sendo certo que foi concedida a ordem para que a paciente aguarde em prisão domiciliar até o

trânsito em julgado da presente ação penal, com imposição de medidas cautelares alternativas (fls. 244/252).

A decisão de fls. 253 determinou o cumprimento da ordem emanada do Eg. Tribunal de Justiça, ordenando a expedição de ordem de liberação em favor da ré Beatriz.

Por outro lado, a decisão de fls. 262/267 indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do réu Vinicius, afastou as preliminares arguidas pela defesa da ré Beatriz e recebeu a denúncia em 20 de setembro de 2022, determinando a citação dos réu, bem como designando audiência de instrução e julgamento.

Alvará de soltura da ré Beatriz cumprido a fls. 271/275.

Em sede de instrução, colheu-se o depoimento de uma testemunha, interrogando-se os réus na sequência (fls. 301/304).

Por ocasião das alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, pugnando pela aplicação da pena acima do patamar mínimo, diante da grande quantidade de droga apreendida (fls. 471/475). De sua parte, a defesa da ré Beatriz sustentou que a versão dos acusados dada em juízo merece credibilidade, dizendo que a cultura policial é no sentido de que quando acha a droga, leva todo mundo e não quer saber da vida pregressa da pessoa, sendo a pretensão procedente em relação à ré, mas cabe dizer que não há qualquer prova de que a mesma integra organização criminosa. Afirmou que a ré é primária e de bons antecedentes, devendo ser-lhe aplicados os benefícios do tráfico privilegiado, nos termos do § 4, art 33, da Lei de Drogas. Não havendo qualquer indicação de integrar organização criminosa, nem mesmo de "mula" do tráfico, ponderou que deve haver a redução máxima da pena, com a fixação da pena em regime aberto e substituída pela restritiva de direitos, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por fim, pediu a isenção das custas processuais à acusada e que a mesma possa recorrer em liberdade.

A defesa do réu Vinicius, de seu lado, apresentou alegações finais a fls. 549/563, afirmando que está ausente a tipicidade quanto ao acusado, pois não foi pego na posse de qualquer substância ilícita, estando sentado ao lado da corré, encontrando-se a droga apenas na bolsa dela, que assumiu a prática do delito.

Alegou que o réu deve ser absolvido ou então que lhe sejam concedidos os benefícios do tráfico privilegiado, nos termos do § 4, art 33, da Lei de Drogas, pois há dúvida quanto à sua autoria, com base no princípio do in dubio pro reo. Afirmou que há segredos entre o casal, entendendo que a ré colocou o seu esposo em uma aventura e ele foi pego de surpresa no momento de sua abordagem, não devendo cair sobre ele qualquer acusação, pois se comprovou nos autos que ele é inocente, devendo ser fixado o regime aberto ou semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade, em caso de condenação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De saída, a despeito da capitulação legal dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 10.343/06, verifico que a denúncia somente descreveu fatos relativos ao delito de tráfico de drogas, razão pela qual passo a apreciar apenas a prática do aludido crime imputado aos réus.

No mais, o presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente, em que pese o esforço das defesas.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra retratada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/08), boletim de ocorrência policial (09/13) autos de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação preliminar (fls. 45/51) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (131/133), além da prova oral colhida nos autos.

Outrossim, a autoria do tráfico de entorpecentes se afigura inequívoca nos autos, recaindo sobre os réus, senão vejamos.

Por primeiro, anoto que os acusados foram presos em flagrante, que configura a certeza visual do crime. De fato, o quadro flagrancial já é mais que incontestável indicativo de autoria. Nesse sentido, "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (TJSP, Apelação Criminal nº 01112349.3/7-0000-000, 2ª Câmara, Rel. Eugênio Augusto Clementi Junior, 05.12.2007).

Quanto às versões apresentadas pelos acusados, na fase policial ambos os réus permaneceram em silêncio (fls. 07/08).

Interrogada em juízo, a ré Beatriz confessou a prática do delito, aduzindo que o corréu não sabia de nada, pois tinham acabado de se casar, motivo pelo qual o convidou para uma viagem a passeio, sendo certo que ele questionou, mas mesmo assim foi. Disse que quando da abordagem pelos policiais, desceu do ônibus e falou ao policial que o corréu era seu marido e que ele não sabia sobre as drogas, sendo certo que o policial foi buscar seu marido no ônibus. Revelou que uma pessoa lhe pagou para ir a Ponta Porã, sendo certo que iria descer na Barra Funda, e entregar a droga para uma pessoa desconhecida. Contou que recebeu ao todo R\$ 3.000,00, R\$ 1.500,00 antecipado e depois receberia mais R\$ 1.500,00. Narrou que estava namorando há 5 meses com o réu e há pouco tempo estavam morando juntos. Indagada, afirmou que é normal não ter segredos entre o casal. Relatou que quem pagou a viagem foi uma pessoa desconhecida, sendo certo que um rapaz que trabalhava com a ré foi o intermediário. Esclareceu que o corréu questionou a origem do dinheiro, pois estavam passando por dificuldades, mas a interroganda disse que fez uma "fezinha", que ele ficou "meio assim", mas ainda assim foi viajar, pois era uma viagem de comemoração pelo casamento. Afirmou que iria pagar as contas do casal com o dinheiro que receberia posteriormente pelo transporte da droga. Contou que o marido é motorista de aplicativo e ficou sem trabalhar durante a viagem. Revelou que pegou a droga próximo de onde "pega a lotação" para voltar a São Paulo, não sabendo dizer se é em Ponta Porã ou em Pedro Juan Caballero. Ressaltou que a sua passagem quem comprou foi a pessoa que a contratou e que a passagem de seu marido foi comprada com o dinheiro que recebeu adiantado. Sustentou que o réu não sabia das drogas e somente soube quando a interroganda foi abordada na rodovia, pois o policial pediu para descer com a bolsa e lhe informou que seu marido não sabia de nada, tanto que nada foi encontrado de ilícito com ele. Asseverou que estava muito nervosa e confessou o crime ao policial, sendo localizada a droga dentro de sua bolsa. Afirmou que pela própria abordagem, os policiais perceberam que o réu não tinha ciência da droga (fls. 304).

Por sua vez, o réu Vinicius negou a prática delitiva, relatando que na data dos fatos estava na companhia da ré, sua namorada, e que não sabia de nada com relação ao que ela estava carregando na bolsa, vindo a saber apenas na hora da abordagem. Não soube dizer de onde os policiais tiraram a versão de que ambos confessaram, pois não disse nada a eles, bem como não tomou conhecimento de onde estava a droga. Depois, esclareceu que ficou sabendo apenas na hora da abordagem, quando foi encontrada na bolsa da corré. Afirmou que foram separados no momento da abordagem e não teve nenhuma oportunidade de fala, sabendo posteriormente que foi localizada droga com a ré (fls. 304).

Quanto à confissão da acusada, anoto não ser usual que alguém se incrimine falsamente, de sorte que a confissão, sobretudo a judicial, tem grande valor probante, salvo se infirmada pelos demais elementos de prova.

Sobre o tema, já se pronunciou o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO JUDICIAL. VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório. (TJ-SP - APL: 993070658932 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 09/11/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2010).

A confissão, máxime a judicial, possui valor probatório elevado, somente podendo ser desconsiderada se o conjunto probatório amealhado nos autos autorizar a conclusão de que ela não representa a verdade dos fatos. Hipótese, ainda, em que a confissão judicial da apelante encontrou eco na confissão da outra ré e ambas foram surpreendidas enquanto mantinham a 'res' em seu poder - Prova suficiente para a

condenação. 2. Prestação pecuniária - Fixação em 05 salários mínimos -Montante excessivo - Apelante primária e que trabalha em uma avícola, presumindo-se auferir parcos rendimentos. 'Res' que foi apreendida e devolvida às vítimas, que por isso não sofreram maior prejuízo - A pena de prestação pecuniária deve ser fixada em valor fixado que seja suficiente e adequado à prevenção e reprovação do crime, mas sempre levando em consideração a situação econômica do condenado e os danos causados a vítima - Recurso provido em parte para reduzir a pena imposta à apelante para 02 salários mínimos. (TJ-SP - APR: 993071218995 SP, Relator: Elias Junior de Aguiar Bezerra, Data de Julgamento: 19/06/2008, 14ª Câmara de Direito Criminal C, Data de Publicação: 06/08/2008).

Todavia, as versões dos réus Beatriz e Vinicius negando o cometimento do tráfico de drogas por parte deste não merece credibilidade, eis que isolada do mosaico das provas.

Com efeito, as testemunhas e policiais militares Jefferson Jose Coimbra e Elias Nunes Cavalheiro, grosso modo, revelaram que, na data dos fatos, por volta das 02:30 horas, realizavam fiscalização pela Base da Polícia Rodoviária desta cidade, localizada na Rodovia Raposo Tavares, Km 616 + 500 metros, com a finalidade de reprimir o tráfico de drogas e realizaram a abordagem de um ônibus da empresa Viação Motta, com origem da cidade de Ponta Porã e com destino a cidade de São Paulo-SP. Durante os trabalhos foram realizadas entrevistas com os passageiros, sendo certo que os passageiros das poltronas de número 33, identificada como Beatriz dos Santos Giles, de 21 anos de idade e na poltrona 34, Vinicius de Freitas, com 22 anos de idade, os quais ao serem entrevistados apresentaram nervosismo e respostas evasivas. Em razão do comportamento dos suspeitos, foi realizada uma vistoria nas bagagens vinculadas aos dois passageiros, os quais mencionaram ser um casal (amásios), sendo certo que na bagagem de mão da passageira Beatriz, uma bolsa de mão de cor rosa, ao ser revistada, puderam encontrar três pacotes plásticos transparentes os quais envolviam em dois deles três invólucros plásticos contendo a droga conhecida por Haxixe (maconha) e no outro pacote mais dois invólucros plásticos contendo em seu interior a droga Haxixe (maconha), somando-se oito invólucros, os quais após serem apresentados neste plantão de Polícia Judiciária, foram fotografados e pesados em balança digital auferindo um peso total líquido de 2,060 Kg e peso bruto de 2,090 Kg lacrados com lacre de número 00016231. Foi localizado na posse da passageira Beatriz um aparelho celular da marca Samsung J4 Core da cor rosa e na posse do passageiro Vinicius um aparelho celular da marca Motorola G6 da cor azul, mais os bilhetes de embarque e bagagem da Viação Motta. Com isso, os autores foram indagados e alegaram que estavam passando por dificuldades financeiras, razão pela qual haviam sido contratados por uma pessoa desconhecida na cidade de São Paulo-SP, para buscarem a droga apreendida na cidade de Ponta Porã-MS, também de pessoa desconhecida e levar para a cidade de São Paulo-SP, também para uma pessoa desconhecida, com isso ganhariam a quantia de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cada um pelo transporte. Esclareceram que foi dada voz de prisão em flagrante aos autuados e conduzidos até o Plantão de Polícia Judiciária para as providências de Polícia Judiciária cabíveis. Anoto que a testemunha Jefferson, única ouvida em Juízo, salientou que a testemunha Elias presenciou tudo que foi narrado. Por fim, disse que nada encontrou de ilícito com o réu Vinicius (fls. 04/06 e 303).

Essa são as provas dos autos, por meio das quais se infere que, de fato, os réus praticaram o crime de tráfico de drogas.

Em relação ao depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão dos acusados, saliento que a situação funcional dos agentes de polícia não os inibe de deporem, e nem uma espécie de suspeição genérica pode retirar-lhes toda e qualquer credibilidade. Importante, assim, é destacar a jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a respeito deste tema:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7), adotando o mesmo sentido TJSP: RT 433/386-7, RT 715/439;

TJPR: RT 554/420 (TJSP - Apelação Criminal nº 278.743.3/5-Garça).

Relembro ainda que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF - RHC - Rel. Min. Moreira Alves - JSTF-Lex 125/332).

Além disso, nada há nos autos a revelar que os policiais teriam alguma razão para injustificadamente incriminar pessoas inocentes, não havendo razão para que servidores públicos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, fossem apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes.

Sobremais, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas atuações, agem escorreitamente. O mesmo não ocorre em relação ao réu, que não está obrigado a dizer a verdade, podendo até mentir para defender seu interesse.

Testemunhas e policiais, via de regra, têm apenas o interesse de contar o que se deu efetivamente, o que coloca suas palavras em elevado grau de confiabilidade, autorizando o édito condenatório. Policiais são agentes credenciados pelo Estado e, como tais, suas palavras devem ser dignas de fé. Afinal, seria um verdadeiro contrassenso revesti-los dessa qualidade e, ainda assim, deles suspeitar. De há muito está superada a corrente jurisprudencial que questiona a presunção de veracidade pela natureza da função exercida.

Melhor elucidando, de acordo com a oitiva dos policiais em solo policial, bem assim da testemunha Jefferson em juízo, os réus, quando foram entrevistados, apresentaram nervosismo e respostas evasivas, vindo a revelar que haviam sido contratados por uma pessoa desconhecida na cidade de São Paulo-SP, para buscarem a droga apreendida na cidade de Ponta Porã-MS, também de pessoa desconhecida e levar para a cidade de São Paulo-SP, com isso ganhariam a quantia de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cada um. Portanto, não merece prosperar a versão da ré de que pela própria abordagem, os policiais perceberam que o réu não tinha ciência da droga.

De outra sorte, não prospera a alegação da defesa do réu Vinícius ao sustentar que ele desconhecia a existência da droga.

Por certo, o erro sobre o elemento do tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, o que não ocorre no caso em comento.

Conforme leciona Julio Fabbrini Mirabete, "Como o dolo deve abranger a consciência e a vontade do agente a respeito dos elementos objetivos do tipo, fica ele excluído se desconhece ou se engana a respeito de um dos elementos de sua definição legal. É o que na doutrina se denomina de erro de tipo, que exclui o dolo por não existir no agente a vontade de realizar o tipo objetivo (...) É uma falsa representação da realidade e a ele se equipara a ignorância, ou seja, o total desconhecimento a respeito dessa realidade (...)." Não é, contudo, essa a situação em tela.

In casu, embora o réu Vinícius tenha sustentado que não sabia da droga encontrada na bolsa de sua companheira, a corré Beatriz, verifica-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que evidenciasse tal alegação.

Além disso, consoante consignado, o policial ouvido em juízo afirmou que ambos os réus estavam nervosos e que confessaram a prática do delito de tráfico de drogas, assegurando que receberiam, cada um, a quantia de R\$ 1.500,00. Noutro giro, em que pese tenha a ré confessado a prática do crime, sustentando que o corréu de nada sabia, revelou que estavam passando por dificuldades, tanto que seu companheiro ficou desconfiado quando o chamou para viajarem até Ponta Porã, tendo a ré "mentido" que teria feito uma "fezinha". Deste modo, diante do conjunto probatório amealhado, não há que se falar em erro de tipo.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio TJSP:

"TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO DOLO DO ACUSADO EVIDENCIADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11. 343/06 INVIÁVEL FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA manutenção das majorações da pena com base nos antecedentes e na reincidência do acusado penas E REGIME INICIAL fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS recursos NÃO providos. (Apelação nº 0000029-12.2014, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em

01/09/2016) APELAÇÃO. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO. PENA MANTIDA. MANUTENÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06, ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (....) 3 Não há que se falar no reconhecimento do erro de tipo, ao argumento de que a ré não tinha conhecimento do que havia no interior daquela mala de viagem, encontrada pelos policiais civis, em seu poder. Isso porque, no caso concreto a defesa não apresentou, no decorrer da instrução processual, um único elemento de prova apto a demonstrar o aventado desconhecimento sobre a elementar do tipo penal. 6. Pena mantida conforme fixada na Origem. 7. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os apetrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primordialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF. 8. Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de narcotráfico será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, as circunstâncias do caso concreto indicam que o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado. 10. Improvimento do recurso defensivo. (Apelação nº 0009703-14.2013, Rel. Des. Airton Vieira, j. em 20/08/2015) – grifei.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição em razão de erro de tipo - Penas adequadas - Possibilidade de aumento da pena-base em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - Precedentes 15ª Câmara de Direito Criminal - Regime inicial fechado devido - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação 0001094-86.2016.8.26.0530; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018) – grifei. Aliás, não é crível que uma mulher que acabou de se casar, tal como disse em seu interrogatório, aceite cometer um crime da gravidade do tráfico de drogas e convide seu marido para viajar com ela sem informá-lo que buscaria entorpecentes em Ponta Porã, cabendo salientar que foi questionada pelo corréu, conforme declarou a ré, bem assim que o acusado aceite viajar com sua companheira para outro Estado da Federação sem saber qual a real razão da viagem, ou ainda sem ter qualquer conhecimento que a corré fosse buscar drogas e as transportasse na bolsa, ainda mais se considerarmos que ambos demonstravam nervosismo e respostas evasivas no momento da abordagem, como revelou a testemunha em juízo.

Isso porque indivíduo que transporta certa quantidade de drogas não exclui a sua responsabilidade criminal, escolhendo permanecer ignorante quanto ao objeto transportado, quando tinha condições de aprofundar o seu conhecimento. Nesse sentido:

"Doutrina da cegueira deliberada equiparável ao dolo eventual é aplicável a crimes de transporte de substâncias ou de produtos ilícitos e de lavagem de dinheiro". (TRF - 4ª Região, ACR nº 5009722-81.2011.404.7002, 8ª Turma, Rel. Sergio Fernando Moro. DOU 23.09.13).

Assim, quem, podendo e devendo conhecer a natureza do ato ou da colaboração que lhe é solicitada, mantém-se em situação de não querer saber, mas, não obstante, presta a sua colaboração, faz-se responsável pelas consequências penais que derivem de sua atuação antijurídica. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse

colocar em cheque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Assim, inegável que ambos os réus praticaram o delito de transporte de drogas, não havendo que se falar em ausência de provas quanto às infrações descritas na denúncia, com a absolvição do réu Vinicius, como postulado pela defesa.

Ademais, a destinação da droga, qual seja, o nefasto comércio, restou plenamente delineada nos autos, ante os depoimentos serenos e uniformes dos policiais militares, os quais revelaram que realizavam fiscalização na rodovia e fizeram a abordagem de um ônibus, vindo a entrevistar os réus, com a exitosa apreensão da droga em seu poder; a quantidade da droga apreendida na bolsa da ré, acondicionada em invólucros plásticos (2,060 Kg de Haxixe - Maconha), incompatível com a alegação de mero uso; a confissão de ambos os réus aos policiais no sentido de que receberiam pelo serviço e da ré Beatriz em Juízo, sustentando que o corréu Vinicius nada sabia sobre o transporte da droga, sintomática da consciência da gravidade do ilícito penal; além da afirmação dos policiais sobre o nervosismo demonstrado pelos réus quando da abordagem, induzem à convicção de que os réus, unidos pelo vínculo da união estável e em razão das dificuldades que estavam passando, sem sombra de dúvidas, praticaram o delito de tráfico de drogas.

Mister salientar ainda que nossas Cortes têm decidido que o tráfico é aferível por indícios, sendo certo que "os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou álibi comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

Com efeito, o crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Vale relembrar também que o simples "trazer consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiros pessoas.

Consigno, outrossim, que não raro, usuários de drogas são também traficantes, muitas vezes para sustento do próprio vício e que a condição de usuário de entorpecentes não exclui a prática de comércio dos tóxicos, sendo possível e comum a coexistência das duas condições.

Assim, a prova produzida é suficiente para a condenação dos acusados, por todas as razões acima expostas.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Atentando para as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que os réus são primários e não ostentam maus antecedentes criminais (fls. 60/65).

Outrossim, há que se considerar a grande quantidade de droga apreendida (2,060 Kg de Haxixe - Maconha), a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006: "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.". Assim, fixo a pena-base dos réus acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, em seu valor unitário.

No mesmo sentido:

"Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de quase meio quilo de maconha, e de uma quantia em dinheiro - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Associação para o tráfico de drogas - Fragilidade do conjunto probatório - Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente - Absolvição de rigor - Penas-base fixadas no mínimo legal a minguia de maus antecedentes, de forma definitiva - Fixação de regime inicial semiaberto - Decorrido o prazo para eventual oposição de Embargos de Declaração ou Infringentes, expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado André - Recursos de apelação parcialmente providos, com determinação, por maioria. Apelação do representante do Ministério Público - Dosimetria da pena -

Fixação das penas-base acima do mínimo legal – Necessidade, diante da quantidade da droga apreendida – Apreensão de quase meio quilo de maconha – Penas redimensionadas – Pretensão quanto à fixação de regime inicial fechado – Disposição legal expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/1990 – Óbice à substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos – Mercês incompatíveis com a singular gravidade do delito – Recurso provido, v.u.." (TJSP; Apelação Criminal 1500484-83.2018.8.26.0559; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2019; Data de Registro: 01/11/2019) – grifei.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico presente a atenuante da confissão em relação à ré Beatriz, razão pela qual torno a pena ao mínimo legal.

Na terceira etapa, como demonstrou a prova colhida nos autos, o tráfico de drogas se deu entre uma unidade da Federação para outra e por meio de transporte público, razão pela qual estão configuradas as causas de aumento de pena previstas no artigo 40, III e V, da Lei nº 11.343/06, de sorte que majoro a reprimenda em 1/5 (um quinto), resultando no montante de 07 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa para o réu Vinicius, e no montante de 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa para a corré Beatriz.

Por outro lado, deixo de aplicar o redutor da reprimenda previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que, não obstante os réus sejam primários, merecem uma resposta penal severa, levando-se em conta ainda a quantidade da droga (2,060 Kg de Haxixe – Maconha), salientando que o crime foi cometido em concurso pelos réus, em transporte coletivo, indicativo de dedicação a atividades criminosas, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Destaco a jurisprudência: "Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas".

(TJSP, 3ª. Câmara de Direito Criminal, Apelação nº. 0000843-72.2011.8.26.00553).

"A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas"

(STF, RHC nº. 94.806, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, 1ª Turma, j. 09.09.2010).

Registro que a utilização da quantidade de droga apreendida com os réus para elevação da pena-base, bem como para o afastamento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não configura bis in idem.

No mesmo sentido a recente decisão a seguir:

"TRÁFICO. Sentença condenatória e v. acórdão que afastaram a incidência do redutor do art. 33, § 4º, das Lei de Drogas. Redutor afastado ao fundamento da dedicação do peticionário à traficância ante à quantidade de drogas com ele apreendidas (71 tijolos de maconha pesando 49 quilos). Ausência de ilegalidade. Divergência jurisprudencial a impedir aplicação da interpretação mais benéfica. Utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não configura bis in idem. Pedido revisional indeferido." (TJSP; Revisão Criminal 0028952-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Cândido Mota - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/10/2022; Data de Registro: 05/10/2022) – grifei.

Por tais razões, entendo que não é caso de se aplicar o previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 07 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa para o réu Vinicius, e no montante de 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa para a corré Beatriz. Cada dia-multa fica fixado no mínimo legal, ante a ausência de elementos seguros e concretos acerca da condição financeira do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena para os delitos será, a teor do art. 2º, §1º, da lei 8.072/90, e considerando a gravidade em concreto da ação criminosa do acusado, o fechado.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, pois tais benesses contrariam a imposição legal quanto à

fixação do regime inicial fechado e ainda porque tal medida não se mostra socialmente recomendável no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para:

A) CONDENAR BEATRIZ DOS SANTOS GILES, RG: 56825118/SP, filha de Edson Marcos Giles e Paula Regina dos Santos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, com as circunstâncias delineadas no artigo 40, incisos III e V, todos da Lei 11.343/06, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ficando cada dia-multa fixado no mínimo legal.

A ré viu o desenrolar do processo em prisão domiciliar, de modo que não se justifica sua soltura após a condenação, haja vista que permanecem intactos os requisitos da prisão cautelar, mantendo-se as medidas cautelares alternativas impostas; e

B) CONDENAR VINICIUS DE FREITAS, RG: 56470863/SP, filho de Maria Aparecida de Freitas, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, com as circunstâncias delineadas no artigo 40, incisos III e V, todos da Lei 11.343/06, além do pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, ficando cada dia-multa fixado no mínimo legal.

O réu viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, de sorte que lhe nego o direito de recorrer em liberdade, considerando-se ainda que tratam os autos de crime que traz evidentes repercussões negativas à sociedade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União.

Outrossim, considerando que não há interesse do SENAD no levantamento perante este Juízo dos aparelhos celulares apreendidos, conforme Ofício nº 897/2016/SENAD-MJ, o que demandaria custos administrativos bem superiores ao seu valor intrínseco e denotaria gestão antieconômica por parte da Administração Pública, autorizo a destruição, após o trânsito em julgado, oficiando-se para este fim à Delegacia de Polícia local.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do Comunicado CG nº 83/2019 e do artigo 525 das NSCGJ, comunicando-se imediatamente a autoridade policial responsável, que deverá enviar a este Juízo o respectivo auto, não podendo o processo ser arquivado sem esta comunicação.

Vencidos, os réus arcarão com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ, observada a gratuidade judiciária deferida.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE n 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 06 de outubro de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA